

刑法  
No.123

H20-11

(配点：3)

|   |   |
|---|---|
| 月 | 日 |
| 月 | 日 |

次のアからオまでの各事例における甲の罪責について、判例の立場に従って検討し、( ) 内の犯罪が既遂になる場合は1を、未遂にとどまる場合は2を、既遂にも未遂にもならない場合は3を選びなさい。

- ア. 甲は、所持金を全く有しておらず、タクシー料金を支払うつつもりはないのに、乙運転のタクシーに乗車したが、乙は、目的地に向けてしばらく走行するうちに、甲の不審な挙動から無賃乗車ではないかと疑い、甲を降車させたため、甲は目的地に到着できなかった。(詐欺罪)
- イ. 甲は、所持金を全く有していなかったが、窃取した他人名義のクレジットカードを持っていたので、代金を支払わずに同カードを使用して飲食店で食事をしようと考え、乙の経営する食堂に入り、飲食物を注文しこれを飲食した後、代金を請求した乙に対し、同カードを手渡したが、既に同カードの名義人から紛失届が出ていたため、同カードを使うことができなかった。(詐欺罪)
- ウ. 甲は、深夜、コンビニエンスストアでおにぎりを万引きして店外に出たところ、これに気付いた店員乙に呼び止められたので、逮捕を免れるため、路上に落ちていた角材で乙を殴るなど同人の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えたが、たまたま通り掛かった通行人に取り押さえられ、逮捕を免れることができなかった。(事後強盗罪)
- エ. 甲は、乙が万引きするのを目撃したことを奇貨として、乙から現金を脅し取ろうと考え、乙にあてて、「万引きをしたのを警察に知られたくなかったら、30万円持ってこい。」などと記載した文書を郵送したところ、乙は同文書を受け取ったが、封を開ける前に誤って捨ててしまったため、甲は現金を手に入れることができなかった。(恐喝罪)
- オ. 甲は、乙を自宅に招いて毒入りの菓子を食べさせて毒殺しようと考え、菓子に致死量の毒薬を混入し、乙に自宅に招待する旨の電話をしたが、乙が多忙を理由にこれを断ったため、乙を殺害することができなかった。(殺人罪)

|        |            |     |     |     |     |     |     |
|--------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| №123   | 実行の着手と既遂時期 |     |     |     |     |     | 正答率 |
| H20-11 | 正解         | ア 1 | イ 1 | ウ 1 | エ 2 | オ 3 | 37% |

## ア 既遂になる

詐欺罪（246条）が成立するためには、詐欺行為により相手方に錯誤を生じさせその意思に基づいて財物又は財産上の利益を交付させることが必要であり、相手方が財物又は財産上の利益を交付しそれによって財物の占有又は財産上の利益が行為者の側に移転した時に既遂となる。そして、労務やサービスも財産上の利益にあたり詐欺罪の客体となるところ、役務の提供があった時点で財産上の利益の移転が認められ、既遂となる。よって、タクシー料金を支払う意思がないのにタクシーに乗車した場合、タクシーの運行が開始された時点で詐欺罪は既遂となる。したがって、本事例の甲は、詐欺既遂罪の罪責を負う。

## イ 既遂になる

支払の意思がないのにその事情を告げずに飲食物を単純に注文する場合、その注文行為自体が欺罔行為となる（大判大9.5.8）。代金支払の意思も能力もないのに不正に入手した他人名義のクレジットカードを使用する場合も同様である。そして、無銭飲食の場合、食事の交付を受けた時点で既遂に達する。よって、窃取した他人名義のクレジットカードを使用する意図で飲食物を注文した時点で詐欺罪の着手が認められ、飲食物の交付を受けた時点で既遂となる。したがって、本事例の甲は、詐欺既遂罪の罪責を負う。

## ウ 既遂になる

事後強盗罪（238条）の既遂・未遂は、「取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅」したかではなく、先行する窃盗罪（235条）の既遂未遂によって決まる（最判昭24.7.9）。そして、窃盗罪の既遂時期は占有取得時（最判昭23.10.23）であり、占有取得の判断は財物の性質・形状・財物に対するそれまでの占有の状況・窃取行為の態様等を考慮して具体的に判断される。おにぎりのように小さく、占有を取得しやすい物は、遅くとも万引きし店外に出た時点では窃盗罪の既遂となっていると考えられる。そして、窃盗犯人たる甲が逮捕を免れるために角材で店員を殴り店員の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた時点で事後強盗罪が成立し既遂となる。したがって、本事例の甲は、事後強盗既遂罪の罪責を負う。

## エ 未遂にとどまる

本事例において、甲の行った脅迫は、万引きを警察に通報するというそれ自体は必ずしも違法ではないものである。このような場合にも「恐喝」があったといえるのが問題となる。この点、判例は、「恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の実現は、必ずしもそれ自体違法であることを要するものではないのであるから、他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官に申告すること自体は、もとより違法でなくとも、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けて他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させることが、恐喝罪となることはいうまでもない。」としている（最判昭29.4.6）。よって、本事例でも「恐喝」があったといえる。また、本事例では、甲の害悪の告知を記載した文書は、乙に到着したがその内容を了知されことなく捨てられてしまっている。このような場合にも恐喝罪の実行の着手は認められるのが問題となる。この点、判例は、恐喝の目的で他人を畏怖させるに足りる文書を郵便に付し、受信人に到達させた以上、受信人においてこれを了知することができなかったとしても、恐喝罪の着手があったといえるとしている（大判大5.8.28）。よって、本事例でも恐喝罪の実行の着手が認められる。そして、恐喝罪が既遂になるためには被害者に財産的損害が生じることを要するところ、本事例においては、乙には何

ら財産的損害が生じていない。よって、本事例において、甲に恐喝既遂罪は成立しない。したがって、本事例の甲は恐喝未遂罪の罪責を負う。

#### オ 既遂にも未遂にもならない

未遂犯の成立が認められるためには、犯罪の実行に着手することが必要とされ、実行の着手に至らなければ、予備・陰謀にとどまり原則として処罰されない。そして、実行の着手とは、構成要件的結果の発生に至る客観的危険性を含む行為の開始をいう（最決昭 45.7.28（百選 I 62 事件）、最決平 16.3.22（百選 I 64 事件）参照）ところ、毒入り砂糖による殺人を意図して、毒入り砂糖を被害者宅に郵送した事案において、判例は、被害者宅への到着時に実行の着手を認めている（大判大 7.11.16、百選 I 65 事件）。これらを前提とすれば、本事例のように菓子に致死量の毒を混入し被害者に電話をしても、毒入りの菓子が被害者の作用領域に入っていない場合は、いまだ実行の着手を認めることはできない。よって、本事例においては実行の着手はなく、未遂罪も成立しない。したがって、本事例の甲は、殺人罪（199 条）の既遂罪の罪責も未遂罪の罪責も負わない。